

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、友人乙がV所有の自動車（以下「V車」という。）の車体をバットで叩いて損壊しているのを発見し、自分も加勢しようと考え、乙に気付かれないように物陰から石を投げ付け、V車の窓ガラスを割った。乙は、その直後に周囲を見回し、物陰にいた甲の姿を見て、甲がV車に石を投げ付けたと認識したが、それ以降は、甲及び乙のいずれも、V車の損壊行為を行わなかった。この場合、甲には、器物損壊罪の共同正犯が成立する。
2. 甲と乙は、友人丙がVから暴行を受けているのを発見し、丙を助けるために意思を通じ、正当防衛としてVに暴行を加えた。これにより、攻撃の意思を失い攻撃をやめたVが現場から逃走したため、甲は、暴行をやめたが、乙は、Vを追いかけて更にVに暴行を加えて傷害を負わせた。その間、甲は、乙の行動に驚き、乙が暴行を加えるのを傍観していた。この場合、甲には、傷害罪の共同正犯が成立する。
3. 甲と乙は、Vに対する強盗を共謀し、乙が先にV方に入り、甲のための侵入口を確保したが、現場付近に人が集まってきたことに気付いた甲は、乙に電話をかけ、「もう犯行をやめた方がよい。先に帰る。」と一方的に告げて、その場から立ち去った。その後、乙は、Vから現金を強取し、その際、Vに傷害を負わせた。この場合、甲には、住居侵入罪及び強盗致傷罪の共同正犯が成立する。
4. 甲と乙は、Vに対する強盗を共謀し、甲がVに包丁を示して、「金を出せ。」と要求したが、甲は、Vに憐憫の情を抱き、Vに「金は要らない。」と言うとともに、乙にも「お前も強盗なんかやめておけ。」と言ってその場を立ち去った。その後もVは甲の脅迫によって反抗抑圧され続けており、乙は、その状態を利用してVから現金を強取した。この場合、甲には、中止犯が成立する。
5. 甲と乙は、Vの殺害を共謀し、甲がVをナイフで切り付けて傷害を負わせたが、甲は、Vに憐憫の情を抱き、犯行をやめようと決意した。甲は、更にVを切り付けようとする乙を羽交い締めにし、Vがその隙に逃走したため、乙は、犯行を継続できず、Vは、死亡するに至らなかった。この場合、甲と乙には、いずれも中止犯が成立する。

1 誤っている

本記述は、甲には、器物損壊罪の共同正犯が成立するとしている点で、誤っている。

大判大 11.2.25。本記述の甲は、乙と同時にV車の損壊行為を行っているが、乙と意思連絡がないことから器物損壊罪の共同正犯が成立するかが問題となる。判例は、片面的共同正犯の成立を否定している。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、共同正犯において一部実行の全部責任の原則を認める趣旨は、共同者各自が相互に他人の行為を利用し補充しあって構成要件的事実を実現することにあるから、**共同実行の意思が各共同者に認められない限り、他人の行為を相互に利用補充しあう関係にはない**ということを挙げている。本記述において、乙はバットでV車を損壊し、甲は石を投げてV車を損壊しているが、意思連絡がなく、共同実行の意思が欠ける。また、乙が甲を認識して以降は、甲及び乙のいずれも、V車の損壊行為を行っておらず、共同実行の事実が欠ける。したがって、甲には、器物損壊罪の共同正犯は成立しない。

2 誤っている

本記述は、甲には、傷害罪の共同正犯が成立するとしている点で、誤っている。

最判平 6.12.6 (百選 I 98 事件)。判例は、本記述と同様の事案において、「相手方の侵害に対し、複数人が共同して防衛行為としての暴行に及び、相手方からの侵害が終了した後に、なお一部の者が暴行を続けた場合において、後の暴行を加えていない者について正当防衛の成否を検討するに当たっては、侵害現在時と侵害終了後とに分けて考察するのが相当であり、侵害現在時における暴行が正当防衛と認められる場合には、**侵害終了後の暴行については、侵害現在時における防衛行為としての暴行の共同意思から離脱したかどうかではなく、新たに共謀が成立したかどうかを検討すべきであって、共謀の成立が認められるときに初めて、侵害現在時及び侵害終了後の一連の行為を全体として考察し、防衛行為としての相当性を検討すべきである**」とした上で、「被告人に関しては、反撃行為については正当防衛が成立し、追撃行為については新たに暴行の共謀が成立したとは認められないのであるから、反撃行為と追行をを一連一体のものとして総合評価する余地はなく、被告人に関して、これらを一連一体のものと認めて、共謀による傷害罪の成立を認め、これが過剰防衛に当たるとした第一審判決を維持した原判決には判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認がある」としている。本記述の甲は、反撃行為として、乙とともにVに暴行を加えているが、正当防衛が成立する。そして、攻撃をやめたVが逃走後、甲は暴行をやめており、乙による追撃行為について新たな共謀もない。したがって、甲には、傷害罪の共同正犯は成立しない。

3 正しい

最決平 21.6.30 (百選 I 97 事件) により、本記述は正しい。

判例は、本記述と類似の事案において、「被告人は、共犯者数名と住居に侵入して強盗に及ぶことを共謀したところ、共犯者の一部が家人の在宅する住居に侵入した後、見張り役の共犯者が既に住居内に侵入していた共犯者に電話で『犯行をやめた方がよい、先に帰る』などと一方的に伝えただけで、被告人において格別それ以後の犯行を防止する措置を講ずることなく待機していた場所から見張り役らと共に離脱したにすぎず、残された共犯者らがそのまま強盗に及んだものと認められる。そうすると、被告人が離脱したのは強盗行為に着手する前であり、たとえ被告人も見張り役の上記電話内容を認識した上で離脱し、残された共犯者らが被告人の離脱をその後知るに至ったという事情があったとしても、当初の共謀関係が解消したということはできず、その後の共犯者らの強盗も当初の共謀に基づいて行われたものと認めるのが相当である」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、共犯関係の解消が認められるためには、離脱者が自己の行為の因果

性を遮断することが必要であるところ、実行の着手前であっても、その後の犯行や結果に対する離脱者の寄与の効果が大きい場合は、離脱者による積極的な犯行防止措置がなければ因果性の遮断は認められないということを挙げている。本記述の甲は、乙の強盗着手前に離脱しているが、犯行をやめる旨を一方的に告げただけで、それ以後の犯行を防止する措置を講じていない。よって、甲と乙の共謀関係は解消されておらず、その後に乙がVから現金を強取し、傷害を負わせたことは、当初の共謀関係に基づくといえる。したがって、甲には、住居侵入罪及び強盗致傷罪の共同正犯が成立する。

4 誤っている

本記述は、甲に、中止犯が成立するとしている点で、誤っている。

最判昭 24.12.17. 判例は、本記述と同様の事案において、共犯者の中1人が自己の意思に因り犯行を中止しても、他の者の犯行を阻止せず放任し、その者が犯行を遂げた場合は、前者に対し中止未遂の規定を適用することはできないとしている。つまり、共同正犯と中止犯の成否について、共同正犯の全員が任意に結果発生を防止した場合は、全員について中止犯が成立する。共同正犯の1人が中止しようとする場合、単独犯の場合と異なり、自己の行為から生じ得る結果の発生を防止するだけでなく、他の者の行為およびそれから生じ得る結果の発生も防止しなければならない。本記述の甲は、Vに憐憫の情を抱き、強盗を中止しているが、乙に「お前も強盗なんかやめておけ。」と言ってその場を立ち去ったのみであり、乙の犯行を阻止せずに放任している。そして、その後、乙が、甲による反抗抑圧状態を利用してVから現金を強取しているので、甲に中止犯の規定を適用することはできない。したがって、甲には、中止犯は成立しない。

5 誤っている

本記述は、乙に中止犯が成立するとしている点で、誤っている。

大判大 2.11.18. 判例は、共犯者の一部の者の中止の効果は他の者に影響しないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、中止犯は一身的な刑の減免事由であるということを挙げている。本記述の甲は、殺人罪の実行に着手したものの、憐憫の情から自己の意思で犯行をやめ、乙を羽交い絞めするなどしてVの死亡結果を防止しているので、中止犯が成立する。これに対し、乙は、Vを切り付けようとしているのに、甲によって犯行を継続できなくなっているため任意性の要件を満たさない。また、甲に成立した中止犯の効果は、乙に及ばない。したがって、乙には、中止犯は成立しない。